

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2754/2556

พนักงานอัยการจังหวัดสงขลา  
นายอาหามะหรืออาฮามะ โต๊ะลู

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 3 (1)

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 65

ความผิดฐานผลิตเฮโรอีนเพื่อจำหน่ายตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 65 วรรคสอง (เดิม) ต้องระวางโทษประหารชีวิตสถานเดียว ศาลอุทธรณ์ภาค 9 จึงพิพากษาให้ประหารชีวิต แต่เมื่อลดโทษให้กึ่งหนึ่งตาม ป.อ. มาตรา 78 ประกอบ มาตรา 52 (2) คงจำคุก 25 ปี เช่นนี้ต้องถือว่าโทษที่ศาลอุทธรณ์ภาค 9 กำหนดตาม คำพิพากษาคือโทษประหารชีวิต มิใช่โทษจำคุก 25 ปี ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 9 ลดโทษให้ กึ่งหนึ่งแล้ว เมื่อปรากฏว่าระหว่างที่จำเลยกำลังรับโทษตามคำพิพากษาซึ่งคดีถึงที่สุด แล้วนั้น ได้มี พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 8 และมาตรา 9 ยกเลิกความในมาตรา 15 และมาตรา 65 แห่ง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 และให้ใช้ข้อความใหม่แทน ซึ่งเฮโรอีนที่จำเลยผลิตโดยการแบ่งบรรจุมีน้ำหนัก 0.30 กรัม เป็นที่เข้าใจว่าหากคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์คงไม่ถึง 3 กรัม เมื่อจำเลยผลิต เฮโรอีนของกลางโดยการแบ่งบรรจุเพื่อจำหน่าย การกระทำของจำเลยจึงต้องด้วย มาตรา 65 วรรคสี่ ที่แก้ไขใหม่ ซึ่งมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและ ปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท อันเป็นคุณแก่จำเลยมากกว่ากฎหมายเดิม เมื่อ โทษที่ศาลอุทธรณ์ภาค 9 กำหนดคือโทษประหารชีวิต หนักกว่าโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึง จำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาทตามกฎหมายที่บัญญัติใน

ภายหลัง ศาลต้องกำหนดโทษให้จำเลยใหม่ตามโทษที่กำหนดตามกฎหมายที่บัญญัติ  
ในภายหลังตาม ป.อ. มาตรา 3 (1) มิใช่ถือเอาโทษจำคุก 25 ปี ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 9  
ลดโทษให้แล้วมาเป็นหลักในการเปรียบเทียบกับโทษที่กำหนดตามกฎหมายที่บัญญัติ  
ในภายหลัง

---

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 26 วรรคหนึ่ง, 75, 66 วรรคหนึ่ง, 76 วรรคหนึ่ง, 91 เรียงกระทรวงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานมี  
เฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุก 6 ปี ฐานมีกัญชาไว้ในครอบครอง จำคุก  
6 เดือน ฐานเสพเฮโรอีน จำคุก 6 เดือน รวมจำคุก 7 ปี โทษส่วนที่เพิ่มและส่วนที่ลด  
เท่ากัน จึงไม่เพิ่มไม่ลด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 54 ธิบของกลาง ข้อหา  
อื่นให้ยก ศาลอุทธรณ์ภาค 9 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดฐานผลิตเฮโรอีน  
เพื่อจำหน่าย ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 65 วรรคสอง  
เฮโรอีนที่ผลิตเพื่อจำหน่ายกับที่มีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเป็นจำนวนเดียวกัน  
เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 65 วรรคสอง ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด  
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้ประหารชีวิต กรณีไม่อาจเพิ่มโทษอีกกึ่ง  
หนึ่งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 97 ได้ จำเลยให้การรับ  
สารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบด้วย  
มาตรา 52 (2) คงจำคุก 25 ปี รวมกับโทษฐานมีกัญชาไว้ในครอบครองและฐานเสพ  
เฮโรอีน คงจำคุก 26 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น คดีถึงที่สุด  
วันที่ 19 ตุลาคม 2544

วันที่ 22 มกราคม 2551 จำเลยยื่นคำร้องขอให้กำหนดโทษจำเลยใหม่ตาม  
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 3 (1)

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้กำหนดโทษจำเลยใหม่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 3 (1) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 65 วรรคสี่ (ที่แก้ไขใหม่), 76 วรรคหนึ่ง (ที่แก้ไขใหม่), 91 (ที่แก้ไขใหม่) ฐานผลิตเฮโรอีนโดยการแบ่งบรรจุ เพื่อจำหน่าย จำคุกตลอดชีวิต ฐานมีกัญชาไว้ในครอบครอง จำคุก 6 เดือน ฐานเสพ เฮโรอีน จำคุก 6 เดือน ฐานผลิตเฮโรอีนโดยการแบ่งบรรจุเพื่อจำหน่ายศาลลงโทษจำคุกตลอดชีวิต จึงไม่อาจเพิ่มโทษอีกกึ่งหนึ่งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 97 ได้ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบมาตรา 53 จำคุก 25 ปี ฐานมีกัญชาไว้ในครอบครองและฐานเสพเฮโรอีน มีเหตุเพิ่มโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 97 กึ่งหนึ่ง และลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง แต่โทษส่วนที่เพิ่มและ ส่วนที่ลดเท่ากัน จึงไม่เพิ่มไม่ลด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 54 คงจำคุก รวม 26 ปี

#### จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 9 พิจารณายกคำร้อง คำสั่งของศาลชั้นต้น และอุทธรณ์ของ  
จำเลย

#### จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยเพียงว่า จำเลยมี  
สิทธิได้รับการกำหนดโทษใหม่ในความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  
พ.ศ.2522 มาตรา 65 วรรคสอง (เดิม) ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 3 (1)

หรือไม่ ข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9 ว่า จำเลยผลิตเฮโรइनโดยการแบ่งบรรจุใส่หลอดพลาสติก 30 หลอด น้ำหนัก 0.30 กรัม เพื่อจำหน่าย และมีเฮโรइनจำนวนดังกล่าวไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ศาลอุทธรณ์ภาค 9 พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานผลิตเฮโรइनเพื่อจำหน่าย ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 65 วรรคสอง (เดิม) เฮโรइनที่ผลิตเพื่อจำหน่ายกับที่มีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเป็นจำนวนเดียวกันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดออกกฎหมายหลายบท ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 65 วรรคสอง (เดิม) ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้ประหารชีวิต กรณีไม่อาจเพิ่มโทษอีกกึ่งหนึ่งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 97 ได้ จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบด้วยมาตรา 52 (2) คงจำคุก 25 ปี ซึ่งความผิดฐานผลิตเฮโรइनเพื่อจำหน่ายตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 65 วรรคสอง (เดิม) ต้องระวางโทษประหารชีวิตสถานเดียว ศาลอุทธรณ์ภาค 9 จึงให้ประหารชีวิต แต่เมื่อลดโทษให้กึ่งหนึ่งแล้วคงจำคุก 25 ปี เช่นนี้ต้องถือว่าโทษที่ศาลอุทธรณ์ภาค 9 กำหนดตามคำพิพากษาคือโทษประหารชีวิต มิใช่โทษจำคุก 25 ปี ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 9 ลดโทษให้กึ่งหนึ่งแล้ว และปรากฏว่าในระหว่างที่จำเลยกำลังรับโทษตามคำพิพากษาซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วนั้น ได้มีพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 8 และมาตรา 19 ยกเลิกความในมาตรา 15 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 และให้ใช้ข้อความใหม่แทนตามข้อเท็จจริงที่ได้ความ เฮโรइनของกลางที่จำเลยผลิตโดยการแบ่งบรรจุ มีน้ำหนัก 0.30 กรัม ซึ่งเป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าหากคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์คงไม่ถึง 3 กรัม เมื่อจำเลยผลิตเฮโรइनของกลางโดยการแบ่งบรรจุเพื่อจำหน่าย การกระทำของจำเลยจึงต้องด้วยมาตรา 65 วรรคสี่ ที่แก้ไขใหม่ ซึ่งมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

อันเป็นคุณแก่จำเลยมากกว่ากฎหมายเดิม เมื่อโทษที่ศาลอุทธรณ์ภาค 9 กำหนดตามคำพิพากษาคือโทษประหารชีวิตหนักกว่าโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท ซึ่งเป็นโทษที่กำหนดตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง ศาลต้องกำหนดโทษให้จำเลยใหม่ตามโทษที่กำหนดตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 9 ถือเอาโทษจำคุก 25 ปี ว่าเป็นโทษที่กำหนดตามคำพิพากษามาเป็นหลักในการเปรียบเทียบกับโทษที่กำหนดตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง แล้วเห็นว่าถือไม่ได้ว่าโทษที่กำหนดตามคำพิพากษาน้ำหนักกว่าโทษที่กำหนดตามกฎหมายบัญญัติในภายหลัง และพิพากษายกคำร้องนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังขึ้น

พิพากษากลับ สำหรับความผิดฐานผลิตเฮโรอีนเพื่อจำหน่าย ให้กำหนดโทษจำเลยเสียใหม่ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง (เดิม), 65 วรรคสี่ (ที่แก้ไขใหม่) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 3 (1) โดยให้จำคุก 15 ปี และปรับ 400,000 บาท เพิ่มโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 97 กึ่งหนึ่ง และลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง ส่วนของการเพิ่มเท่ากับส่วนของการลด เห็นสมควรไม่เพิ่มไม่ลด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 54 เมื่อรวมกับโทษฐานมีกัญชาไว้ในครอบครองและฐานเสพเฮโรอีนฐานละ 6 เดือน เข้าด้วยกันแล้ว เป็นจำคุกจำเลยทั้งสิ้น 15 ปี 12 เดือน และปรับ 400,000 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 หากจะต้องกักขังแทนค่าปรับก็ให้กักขังแทนค่าปรับเกิน 1 ปีได้ แต่ไม่เกิน 2 ปี

(ประทีป ดุลพินิจธรรมมา-สุนทร ทรงฤกษ์-สุริยง ลี้มสถิรานันท์)

ศาลจังหวัดสงขลา - นายศุภชัย พุจิตร

ศาลอุทธรณ์ภาค 9 - นายชนะ ภาสกานนท์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอุทธรณ์ 2609/2543

ต้น

หมายเหตุ